

1500768-12.2022.8.26.0540
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella
Comarca: Mauá
Foro: Foro de Mauá
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/05/2022
... Paulo:

MATERIALIDADE [...] AUTORIA [...] TRÁFICO [...] PENA - base no mínimo, em que pese quantidade, variedade e natureza das drogas, visto inexistência de recurso ministerial - segunda fase presente a reincidência específica e menoridade - reincidência específica que indica maior desvalor e impõe aumento de 1/3 - precedentes das Cortes Superiores - menoridade que indica redução ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mauá
Foro de Mauá
2ª Vara Criminal
Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500768-12.2022.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500768-12.2022.8.26.0540
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GUSTAVO LIMA DE ALMEIDA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

GUSTAVO LIMA DE ALMEIDA foi denunciado por incursão no inciso III e IV do parágrafo 4º do artigo 155 c.c inciso II do artigo 14, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 18 de abril de 2022, por volta das 11h45min, na Avenida Luís Gonzaga do Amaral, altura do número 52, Jardim Zaíra, nesta cidade e comarca de Mauá, o acusado, previamente ajustado e agindo com identidade de propósitos com pessoa não identificada, tentou subtrair, para proveito comum e com emprego de chave falsa, o veículo GM/Corsa Wind, placas BPL-1009, avaliado em R\$ 8.000,00 (fls. 15), pertencente a Henrique Miguel da Silva Guilherme, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fl. 96) e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução, a testemunha arrolada pelas partes foi devidamente inquirida.

Por fim, interrogou-se o réu.

Em memoriais escritos, pleiteia o Ministério Público a procedência da ação nos termos da denúncia, enquanto a Defesa requer a absolvição ante a insuficiência probatória ou, ao menos, a exclusão da qualificadora do emprego de chave falsa, a aplicação da pena nos patamares mínimos, reconhecendo-se a atenuante da confissão e a causa de diminuição da tentativa em seu grau máximo, a fixação de regime penitenciário inicial aberto e a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Procede a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 07-9), auto de exibição e apreensão (fl. 12-3), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 14), auto de avaliação (fl. 15) e prova oral colhida.

Evidente a autoria.

Interrogado, em solo policial, o réu permaneceu em silêncio (fl. 06). Sob o contraditório, admitiu que tentou furtar o veículo, alegando contudo que estava sozinho, pois o outro indivíduo era apenas um transeunte. Confirmou ter feito o uso de chave falsa (mídia digital).

A vítima, na fase administrativa, afirmou que soube da tentativa de furto do seu veículo, porém não presenciou o ocorrido (fl. 05).

A testemunha Willian, na fase antejudiciária, historiou que (sic) "trabalha como mecânico automotivo na oficina "Tata", situada na Rua João Paulino de Farias. O declarante estava trabalhando próximo a porta da oficina, que estava aberta, quando viu dois indivíduos em atitude suspeita andando na rua. Que alguns minutos depois saiu na calçada e observou que os mesmos indivíduos já haviam invadido um veículo GM/Corsa que estava estacionado próximo da oficina. O declarante foi andando em direção ao veículo e gritando "o que vocês estão fazendo aí?". Os indivíduos, que estavam tentando ligar o veículo se assustaram, saíram do carro e se evadiram ocorrendo, sendo que na fuga, um dos indivíduos arremessou um objeto, o qual o depoente acredita que possa ser uma chave "mixa" em um matagal próximo, sendo que o referido objeto não foi localizado. O depoente utilizou seu telefone celular para comunicar o fato pelo "190". O depoente no telefone para a PM descreveu com detalhes as características físicas dos autores da tentativa de furto. Poucos minutos depois a uma viatura da Polícia Militar chegou ao local informando que havia detido um dos autores. A vítima, proprietário do veículo, que é vizinho da oficina chegou ao local. O depoente nesta distrital, em sala apropriada, colocado diante de três indivíduos, prontamente reconheceu sem sombra de dúvida a pessoa de GUSTAVO LIMA DE ALMEIDA, RG 64078041 - SP, como sendo um dos autores da tentativa de furto, mais precisamente como o indivíduo que se sentou no banco do motorista, que estava tentando ligar o veículo, e que, na fuga, arremessou o objeto no matagal" (fl. 04).

Em juízo, reiterou integralmente a dinâmica do ocorrido. Disse que estava trabalhando e, ao sair da oficina, visualizou o réu dentro do veículo em questão. Acreditando ser um veículo deixado para reparos, foi em sua direção e questionou o que ele estava fazendo, momento em que o suspeito saiu correndo. Depois de um tempo, o acusado retornou com outro indivíduo e novamente embarcou no veículo, tentando subtraí-lo. Na ocasião o réu disse que o carro era de um amigo dele, o que não era verdade, pois pertencia a um vizinho do estabelecimento. Afirmou que o

acusado tinha uma chave falsa, mas ela foi dispensada durante a fuga. Nesta segunda tentativa de subtração, ele e o comparsa novamente fugiram, porém acionou a polícia e informou as características físicas dos suspeitos. Logo depois, a polícia militar conseguiu deter o réu (mídia digital).

O policial militar, na fase administrativa, historiou que (sic) "na manhã de hoje, na companhia do também policial militar Jonathan Duarte que dirigia a viatura oficial, estavam em patrulhamento de rotina quando foi irradiada a informação de uma tentativa de furto de veículo pelo local dos fatos, onde chegaram minutos após e em contato com a testemunha William Veleis da Silva, esta relatou que trabalha numa oficina mecânica TATA AUTO MECÂNICA quando foi alertado por sua patroa a respeito de um indivíduo suspeito rondando os veículos estacionados na rua em frente, alguns inclusive que seriam de clientes e que ali estariam para reparos. Recebido o alerta por parte de sua patroa, decidiu então sair para a rua em frente, dar uma averiguada e ver o que estaria ocorrendo e então se deparou com um indivíduo desconhecido no interior de um veículo GM/CORSA WIND, estacionado na rua e que tal indivíduo tão logo o avistou, desembarcou do veículo e se evadiu do local em desabalada carreira e observou que ele calça chinelo de dedo na cor branca, bermuda jeans e blusa de moletom na cor cinza. Com as características do autor dos fatos, passadas pela testemunha prosseguiram em patrulhamento e 200 metros depois vieram a localiza-lo ainda em fuga, sendo então detido logo em seguida e na revista que foi feita nada de ilícito foi encontrada em sua posse e em poder do autor, além de sua carteira com seus documentos pessoais e um telefone celular, estava um Alvará de Soltura, [...] e ao ser questionando o autor dos fatos identificado como sendo GUSTAVO LIMA DE ALMEIDA, admitiu a prática do delito em tela ao tentar furtar o veículo estacionado em via pública e que havia feito uso de uso de uma chave mixa para abri-lo e que a havia dispensado enquanto corria para tentar se livrar" (fls. 02-3).

As qualificadoras do concurso de agentes e do emprego de chave falsa foram devidamente comprovadas pela prova oral colhida, notadamente a palavra da testemunha William.

Registre-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, nem sempre o emprego de chave falsa provoca danos no veículo, de forma que a perícia em nada contribuiria para a prova da qualificadora. Note-se que, não obstante a ausência de laudo pericial do veículo em questão, o ofendido, na fase administrativa, afirmou que seu carro (sic) "não sofreu nenhum tipo de dano" (fl. 05).

Assim, considerando as declarações da testemunha William, no sentido de que o réu tinha em seu poder uma chave falsa e estava tentando ligar no veículo, de rigor o reconhecimento da qualificadora, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

Nessa linha:

"Este Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg no EAREsp 886.475/SC (Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 27/2/2019, DJe 12/3/2019), firmou entendimento no sentido de que "a necessidade de realização do exame pericial à constatação da qualificadora de uso de chave falsa (art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal) dependerá das circunstâncias fáticas de cada caso. Se houver vestígios, a perícia é imprescindível, na forma do art. 158 do Código de Processo Penal. Naqueles em que não forem eles verificados ou se já desapareceram, a prova oral poderá suprir a técnica, conforme disposto no art. 167 do Código de Processo Penal" (STJ, AgRg no HC 628.159/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Furto qualificado - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Absolvição por fragilidade de provas - Impossibilidade - Emprego de chave falsa admitida pelo

apelante - Pleito de afastamento da qualificadora prejudicado - Desnecessidade do laudo pericial ante ausência de vestígios que viabilizem a produção de prova técnica - Condenação mantida - Recurso improvido. [...] (TJSP; Apelação Criminal 0000149-20.2016.8.26.0136; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cerqueira César - 1ª Vara; Data do Julgamento: 20/09/2021; Data de Registro: 20/09/2021 - grifo nosso).

O réu somente não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, já que foi flagrado durante a prática delitiva, o que fez com que fugisse do local, sem conseguir subtrair o veículo.

Dentro deste espectro, comprovadas a materialidade e autoria delitiva, passo à dosagem das penas.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, diante da multiplicidade de qualificadoras, sendo que o emprego de chave falsa foi utilizado para qualificar o crime e o concurso de agentes para exasperar a reprimenda, perfazendo, 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa. Neste sentido:

"(...) O apelante foi beneficiado com a fixação da pena base no piso legal, haja vista a multiplicidade de qualificadoras, sendo que, uma delas poderia ter sido utilizada para qualificar o crime e, as demais, para exasperar a reprimenda básica". (TJSP, Apelação Criminal nº 1500815-20.2021.8.26.0540, Rel. Des. FERNANDO SIMÃO, j. 16.03.22).

"APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA - CONFISSÃO E DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL AMPARADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS - PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA - UTILIZAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA PARA QUALIFICAR O CRIME E OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - PENA-BASE - FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59 DO CP DESFAVORÁVEIS - REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO - POSSIBILIDADE DEVIDO À REINCIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. A confissão e a delação extrajudicial, amparadas nos depoimentos das testemunhas e nos demais elementos dos autos, formam prova robusta para condenação. Não caracteriza bis in idem a utilização de uma das qualificadoras para qualificar o crime do furto duplamente qualificado, e outra como circunstância judicial. Impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, diante das circunstâncias do artigo 59 do CP desfavoráveis, o que também justifica a fixação do regime fechado para cumprimento de pena, mormente se o réu é reincidente." (TJ-MS - APR: 10350 MS 2005.010350-7, Relator: Des. Carlos Stephanini, Data de Julgamento: 07/03/2006, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/03/2006)

"HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, havendo pluralidade de qualificadoras, possível que uma seja utilizada para caracterizar o tipo qualificado e a outra como circunstância judicial desfavorável. 2. No caso, incidiam as qualificadoras do abuso de confiança e do concurso de agentes, sendo que uma serviu para a tipificação do crime de furto qualificado e a outra como circunstância judicial desfavorável - motivo pelo qual a pena-base foi fixada acima do mínimo legal -, não havendo qualquer constrangimento ilegal ocasionado ao paciente. 3. Ordem denegada." (STJ - HC: 202035 SP 2011/0070113-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 02/06/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2011)

Na segunda etapa, tendo em vista a reincidência específica (certidão de fl. 44 - proc. 1523913-97.2021) e a menoridade relativa (19 anos - fl. 16), suficiente o

acréscimo de mais 1/6 à reprimenda, totalizando 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Sobre a compensação parcial da atenuante da menoridade relativa diante da especificidade da recidiva, manifestou-se o c. Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPÇÃO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de ilegalidade no aumento da pena-base, tendo-se utilizado de uma condenação anterior, já extinta pelo cumprimento, como maus antecedentes e outra para o aumento pela reincidência. Ausente qualquer referência à utilização de condenação sem o devido trânsito em julgado. A ilegalidade apontada nos autos de habeas corpus, de cognição sumária, deve estar demonstrada de plano, não se admitindo dilação probatória. 2. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de serem igualmente preponderantes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, não sendo viável, contudo, a compensação integral das mencionadas agravante e atenuante, quando se tratar de reincidência específica. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 415.804/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018 - grifo nosso).

Na mesma linha o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

MATERIALIDADE [...] AUTORIA [...] TRÁFICO [...] PENA - base no mínimo, em que pese quantidade, variedade e natureza das drogas, visto inexistência de recurso ministerial - segunda fase presente a reincidência específica e menoridade - reincidência específica que indica maior desvalor e impõe aumento de 1/3 - precedentes das Cortes Superiores - menoridade que indica redução de 1/6 - compensação parcial - aplicação de aumento de 1/6 - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - terceira fase, redutor afastado pela reincidência - manutenção do regime fechado (TJSP; Apelação Criminal 1500650-07.2019.8.26.0228; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 16ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020 - grifo nosso).

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11.343/06 - COEXISTÊNCIA DA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA OU COMPENSAÇÃO INTEGRAL - NÃO ACOLHIMENTO. Diante da confissão espontânea e da reincidência do réu, ambas deveriam ser compensadas, na medida em que não há que se falar em preponderância de uma sobre a outra, de acordo com o artigo 67 do Código Penal. No entanto, a reincidência específica impossibilita a compensação integral. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000223-55.2017.8.26.0616; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/07/2019; Data de Registro: 19/07/2019 - grifo nosso).

No caso dos autos, a reincidência específica justifica referida fração de aumento, já que maior o desvalor da conduta. Neste sentido, precedente do e. Superior Tribunal de Justiça:

"A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o

princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)" (HC nº 257.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18/02/2014).

Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea e parcial, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, ainda em fuga, logo após tentar furtar o veículo, e buscou falsear a verdade, a fim de atenuar sua responsabilidade, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recruto de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a princípio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à

Justiça”.

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022). g.n.

"(...) Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque Paulo foi preso em flagrante vendendo drogas a um adolescente e outro indivíduo, de modo que sua confissão não foi utilizada para formação da convicção. O flagrante e os depoimentos das testemunhas são suficientes para sustentar sobremaneira o édito condenatório." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500902-44.2018.8.26.0616,, rel. Des. Roberto Porto, j. 18.6.2020, V.U.).

"(...) Ademais, sobreleva registrar que a referida confissão não foi utilizada pelo magistrado sentenciante como elemento de convicção, não incidindo, assim, na hipótese, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Veja que, para o reconhecimento da finalidade mercantil da droga apreendida com o acusado, o douto juiz não utiliza de sua confissão a esse respeito, mas sim dos demais elementos de convicção colhidos." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500646-88.2020.8.26.0630, rel. Des. Camilo Léllis, j. 22.3.2022, V.U.).

Apelação criminal - Tráfico de drogas - [...] Dosimetria - pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de

Drogas. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Confissão que não foi considerada na formação do convencimento do julgador. [...] Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. "[...] verificando-se que neste caso, não houve qualquer menção ao teor do interrogatório do acusado para a formação do convencimento do douto Julgador para o deslinde desta ação penal, não há como se acolher o pleito de consideração da referida atenuante de pena, nos termos dos abalizados entendimentos jurisprudenciais referidos." (TJSP; Apelação Criminal 1500255-44.2022.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2022; Data de Registro: 08/05/2022).

Não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, recentemente:

"Agravamento regimental no habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Matéria não analisada na apelação. Ônice à inovação em sede de embargos de declaração. Constrangimento ilegal inexistente, Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça STJ. Édito condenatório apoiado em outros elementos. Não incidência. Precedentes. Agravamento regimental desprovido. 1. [...] 2. Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo portanto, inviável a redução da reprimenda. Precedentes, 3. Agravamento regimental desprovido (STJ AgRG no HC 648.216/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe, 15.06.2021).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ABRANDAMENTO DA PENA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O enunciado n. 545 da Súmula desta Corte prevê que "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". Da leitura da sentença condenatória e do acórdão impugnado, observo que, embora o paciente tenha apresentado uma versão para os fatos, essa confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu de outros meios de prova. Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante. 2. Agravamento regimental desprovido. (AgRg no HC 613736/RJ, QUINTA TURMA, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. em 30/03/2021, DJe 13/04/2021). g.n.

Na última fase, reconhecida a tentativa, observado o iter criminis percorrido - réu surpreendido dentro do carro, tentando ligá-lo - procede-se a diminuição da pena em 1/2, definindo-se a condenação em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 06 dias-multa.

O valor do dia multa será o unitário mínimo.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal, notadamente pela reincidência.

Pelas mesmas razões não se aplicam outros benefícios legais, insuficientes para a reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu GUSTAVO LIMA DE ALMEIDA, qualificado nos autos, às penas de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, sob o regime inicial semiaberto, e a pagar 06 dias-multa, no unitário mínimo, por infração aos incisos III e IV do parágrafo 4º do art. 155 c.c. inciso II do art. 14, ambos do Código Penal.

Denego o apelo em liberdade, mantidos os fundamentos da custódia cautelar.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA